

1501233-48.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Willi Lucarelli

Comarca: Embu-Guaçu

Foro: Foro de Embu-Guaçu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º DA LEI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu-Guaçu

Foro de Embu-Guaçu

Vara Única

Rua Boa Vista nº 10, Embu-Guaçu-SP - cep 06900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501233-48.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501233-48.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178248/2022 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 25889728 -

DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2178248 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDGAR APARECIDO ALVES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli

VISTOS.

EDGAR APARECIDO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 01 de julho de 2022, pela manhã, no endereço descrito com a inicial, o denunciado guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 76 porções de cocaína, 24 porções de maconha e 70 pedras de crack, em desacordo com determinação legal.

Processada, a denúncia fora recebida. Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais durante a audiência.

DECIDO.

Cumpre reconhecer que, na análise da pretensão punitiva deduzida, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 32/34), pelo laudo toxicológico (fls. 80/82) e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, diversamente do que afirmado pela combativa defesa, a prova vinda aos autos demonstrou, à saciedade, a responsabilidade criminal do réu, servindo, assim, de fundamento para o presente decreto condenatório.

É certo que o réu, na fase judicial, negou o ocorrido, aduzindo, em síntese, que ia comprar drogas, de modo que, no instante em que ia adentrar à biqueira, foi surpreendido pela polícia, que acabou por levá-lo para o mato, onde encontraram anotações e lhe imputaram falsamente.

O denunciado disse, ainda, que foi agredido com madeirada nas costas.

Contudo, as suas alegações não encontram amparo na prova oral colhida nos autos, que foi firme e segura em confirmar todo o desenrolar fático apontado pela denúncia.

Nesse sentido, o guarda municipal CLAUDIO FRANCISCO, na fase judicial, disse que, durante patrulhamento de rotina, se deparou com dois indivíduos em atitude suspeita, sendo certo que em poder do réu havia um pedaço de papel com anotações e com GABRIEL nada de ilícito foi encontrado.

O agente público afirmou, ainda, que, em seguida, localizou uma sacola contendo drogas a cerca de três metros do denunciado, sendo certo que GABRIEL indicou o denunciado como o responsável pelos entorpecentes.

Da mesma forma, foram as declarações do guarda municipal MALCO na fase judicial.

Na fase policial, os guardas municipais trouxeram idêntica versão para os fatos (fls. 07/08).

Não há provas que tenham o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato praticado pelos guardas municipais, de modo a indicar que a diligência policial foi perpetrada em função de interesses escusos.

Realmente, não se nega que, por vezes, haja desvios de finalidade na prática de atos administrativos, infelizmente, movidos por interesses que não se compatibilizam com as funções precípuas do Estado, mas não parece ser o caso dos autos.

É que não seria razoável que os guardas municipais tivessem apreendido drogas, mais dinheiro e falsamente imputassem a indivíduo que sequer tinham qualquer rixa ou desentendimento.

Acerca da alegação do réu de que os GCM's forjaram a diligência, cabe salientar que a questão carece de provas, devendo-se destacar, também, que o exame de corpo de delito não apontou lesão corporal compatível com a natureza das agressões descritas pelo denunciado.

É que o laudo identificou "escoriações superficiais lineares em região anterior de antebraço direito" (fls. 53), ao passo que o réu descreveu que teria sido agredido

com chutes e ripas de madeira.

Na verdade, muito provavelmente, as escoriações descritas devem estar relacionadas à dinâmica da detenção, especialmente a mencionada tentativa de reação do denunciado, tal como narrou o guarda municipal CLAUDIO FRANCISCO na fase judicial.

Portanto, no caso em exame, tenho por justificada a lesão constatada.

Em acréscimo, não se pode desconsiderar que GABRIEL DIEGO, na fase policial, disse que “a droga era de EDGAR” (fls. 09), declarações que atribuem ainda mais veracidade aos informes dos guardas municipais.

É certo que, na fase judicial, GABRIEL voltou atrás e afirmou que não fez tal acusação, no entanto, tudo está a indicar que, na verdade, pretendia beneficiar o denunciado EDGAR.

Na medida em que, além de também estar preso no mesmo estabelecimento prisional (CDP de Itapecerica da Serra), apresentou contradição em seu depoimento, eis que descreveu relação próxima com o réu, o que foi negado pelo próprio denunciado EDGAR na fase judicial.

Desse modo, de rigor sejam desconsideradas as declarações de GABRIEL na fase judicial, inservíveis, por conseguinte, como elemento de prova em favor do denunciado.

Em suma, a diligência enquadra-se na grande maioria dos atos administrativos, ou seja, daqueles realizados de forma legítima e segundo os ditames da boa-fé.

Em arremate, mister salientar que não há qualquer ilegalidade na atuação da Guarda Municipal no caso dos autos, porquanto se tratou de situação de flagrante delito, que se revela cabível, diante do teor do artigo 301 do Código de Processo Penal.

De fato, dispõe o artigo 144 da Constituição Federal que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de diversos órgãos.

A atribuição da guarda municipal insere-se nesse contexto, não só para fins de patrulhamento preventivo, como também para o uso progressivo da força, conforme disposto no artigo 3º, incisos III e V, da Lei Federal nº 13.022/2014, cabendo-lhe também “colaborar, de forma integrada, com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social” e “encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração” nos termos previstos no artigo 5º, IV e XIV, da citada legislação.

Em acréscimo, cabe destacar que não era necessária qualquer investigação prévia por parte dos agentes municipais, que estavam realizando ronda por local notoriamente conhecido pelo comércio de drogas, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita.

No mais, a revista pessoal está expressamente autorizada nos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, independentemente, de ordem judicial.

Na hipótese vertente, como já destacado, os agentes públicos estavam em local conhecido pela mercancia de entorpecentes e o denunciado apresentou atitude manifestamente suspeita, justificando a atuação da Guarda Municipal.

A esse respeito, confira-se o seguinte julgado da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE PELA ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE LEGITIMAM A AUTUAÇÃO DA REFERIDA ENTIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA BASILAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - Inicialmente, no que se refere à pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, verifico tratar-se de inovação recursal em sede de agravo regimental, uma vez que tal pretensão não foi feita na inicial do writ, o que não é admitido pela jurisprudência. Ademais, ainda que assim não fosse, a reincidência do agravante obsta a concessão da benesse, não havendo que se falar em bis in idem. Precedentes.

III - No que se refere à preliminar de nulidade pela atuação da guarda municipal, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar a referida alegação que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal que, embora ressalte ser descabida a realização de investigações de práticas de ilícitos, disso não se desume a possibilidade de, mediante notícia de crime, proceder a diligências de averiguação, haja vista a possibilidade de prisão em flagrante, como ocorreu no presente caso. Com efeito, como bem observado pela Corte de origem, "os Guardas Municipais, assim como qualquer outra pessoa do povo, ao contrário do entendido externado pela nobre Defesa, pode deter alguém pela prática de crime, desde que em flagrante delito" (fl. 88), não havendo que se falar em nulidade por este fundamento. Precedentes.

IV - Outrossim, descabida a alegação de que a basilar foi aumentada de forma inidônea, haja vista que a sentença condenatória levou em consideração a natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas, tratando-se de "04 porções de maconha, com peso líquido de 0,74g; 50 porções de maconha, com peso líquido de 105,98g; 23 porções de cocaína, com peso líquido de 11,93g; 23 porções de cocaína, com peso líquido de 15,2g; e 31 porções de cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 5,02g" (fl. 46), aplicando a fração de 1/6 (um sexto), tudo de acordo com o entendimento deste Tribunal. Precedentes.

V - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 748.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.).”

Nesse panorama, é indiscutível a veracidade dos fatos articulados na denúncia, constituindo a conduta afronta ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, eis que presentes a autoria, a materialidade, o dolo específico e a tipicidade da conduta.

Portanto, passo a dosar a pena:

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, majoro a reprimenda em 1/6, em razão da reincidência do réu, que foi condenado, com trânsito em julgado, nos autos do Processo n.º 2089-62/2017 (fls. 109), totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, eis que a aplicação do dispositivo demanda o preenchimento cumulativo de seus requisitos, desde que associados às circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas.

No presente caso, o réu guardava drogas dos mais diversos tipos para entrega a terceiros, sendo que esta peculiaridade, aliada à condenação, com trânsito em julgado, em desfavor do réu, inclusive, pelo crime de tráfico de drogas (Processo n.º 2089-62/2017 - fls. 109), permitem a conclusão de que não se trata de traficante não habitual.

Sobre a reincidência como motivação idônea para a negativa à aplicação da causa de diminuição, confira-se o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que a análise anterior das matérias objeto do recurso especial nos autos de habeas corpus impetrado com idênticos fundamentos e pedidos implica perda de interesse recursal e prejudicialidade da pretensão recursal. Precedentes.
3. Na espécie, os pleitos atinentes à desproporcionalidade do quantum incrementado à pena-base e ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena foram anteriormente apreciados por este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 672.615/SP, impetrado pela mesma parte, contra o mesmo acórdão, sob os mesmos fundamentos e com os mesmos pedidos. Assim, inafastável o reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial, nos pontos.
4. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.
5. In casu, consoante asseverado pelas instâncias ordinárias, o recorrente ostenta múltiplas condenações anteriores, também por tráfico de drogas, configuradoras de maus antecedentes (e-STJ fls. 465 e 609) - o que, por si só, constitui fundamentação idônea para afastar a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 -, além de ter sido preso em flagrante delito por transportar e guardar, para fins de tráfico, 163,480kg de cocaína (e-STJ fl. 602). Nesse contexto, inviável a aplicação da privilegiadora postulada.
6. Agravo regimental não provido. (grifo nosso). (AgRg no REsp 1970177/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).”

Portanto, sob todos os ângulos analisados, o réu não faz jus à causa de diminuição.

Sendo assim, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, fixo em 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,

corrigido monetariamente, a contar da mesma data.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando as provas de que se dedicava a atividades criminosas, de modo que a imposição de regime menos rigoroso não surtirá qualquer efeito.

Neste sentido, confira-se o seguinte julgado, consoante aresto que passo a transcrever:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que a Corte de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.
 2. As peculiaridades do caso concreto (quantidade e natureza da droga, bem como a dedicação do acusado ao narcotráfico) justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.
 3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
 4. Agravo regimental não provido.
- (AgRg no HC 566.498/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)."

Não havendo qualquer influência o tempo de pena provisória cumprida, para fins de detração penal, porquanto ofensiva ao princípio do juiz natural e da individualização da pena.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Não se nega que, em função da cautelaridade da prisão provisória, o pedido deve ser juridicamente possível, ou seja, não deve encontrar obstáculo em qualquer das vedações legais previstas na Lei n.º 12.403/11.

Contudo, no caso em exame, houve decreto de prisão preventiva (fls. 56/58), que esteve a considerar todas estas circunstâncias legais e fáticas, em decisão não impugnada pela Defesa.

E, neste meio tempo, nada houve que tivesse o condão de apontar a existência de fatos novos, inclusive jurídicos, senão aqueles que subsidiaram a r. decisão lançada.

Sendo assim, ainda mais agora que todo o contexto probatório está a indicar ter sido o réu autor do delito, nada há que esteja a justificar nova apreciação do pedido, sob pena de, por via transversa, desfazer-se situação jurídica consolidada e suprimir instância judicial.

Assim, sob todos os ângulos analisados, não há qualquer constrangimento ilegal que esteja sendo imposto à liberdade de locomoção do réu, sendo de rigor a manutenção da medida.

Ante o exposto, CONDENO EDGAR APARECIDO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, À PENA DE 05 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, e 500 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo na data dos fatos, corrigido monetariamente, a contar da mesma data, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

DECRETO a perda, em favor do Estado de todos os bens apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Custas na forma da lei.
Registre-se e comunique-se, com as anotações de estilo.

Embu-Guacu, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA